

1500222-92.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDE JOSE DA SILVA

Data da Audiência:

01/09/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500222-92.2021.8.26.0571 - Controle 2021/000201

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDE JOSE DA SILVA

Data da Audiência:

01/09/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente o acusado Fernando José da Silva que se encontra em liberdade e não foi encontrado, conforme fls. 202. Foi ouvida a testemunha Marcelo Ribeiro da Cruz. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Tânia Rafaela Amaro, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O depoimento foi registrado pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Decreto a revelia do acusado e não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 09 de fevereiro de 2021, às 18h, na Rua Pilar do Sul, 595, Vila Paulo Ayres, nessa cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito: a) 75 (setenta e cinco) porções de "cocaína", com peso bruto de 67,78g; b) 36 (trinta e seis) de "maconha", com peso bruto de 85,58g; e c) 07 (sete) de "cocaína" sob a forma de "crack", pesando 4,81g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 119/120). A denúncia foi recebida em 08/11/2021 (fls. 121). O réu foi citado por edital, não constituiu advogado nem compareceu em juízo, motivo pelo qual o processo e o prazo prescricional foram suspensos com fundamento no artigo 366 do CPP (fls. 133/134). Após, o acusado foi pessoalmente citado (fls. 155). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu não foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação (fls. 18/19) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 58/61). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse que realmente estava vendendo drogas. Quando avistou a viatura, tentou fugir com sua bicicleta, mas acabou caindo. Contou que os policiais acharam "cocaína" consigo e, em seguida, localizaram mais drogas no local em que as escondia. Afirmou que vendia a porção de "maconha" por R\$ 5,00 e por R\$ 10,00 as porções de "cocaína" e "crack" (fls. 06). O réu, na instrução, optou pela revelia. A prova oral também é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento e avistaram o denunciado manipulando algo no chão. O acusado, ao notar a presença policial, imediatamente se levantou e passou a andar com sua bicicleta, o que gerou suspeita nos agentes públicos.

Quando FERNANDE acreditou que seria abordado, se assustou e tentou deixar o local rapidamente, mas acabou caindo no solo. A conduta do denunciado reforçou as suspeitas dos militares de que havia algo de irregular, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Procedida a revista pessoal, os policiais encontraram 10 porções de "cocaína" e a importância de R\$ 47,00 em dinheiro. Todos retornaram ao local em que FERNANDE estava abaixado manipulando algo, ocasião em que localizaram, em um "tapete de grama", 35 porções de "maconha" e outra porção maior da mesma droga, além de 65 porções de "cocaína" e 07 pedras de "crack". Indagado, o acusado confessou que estava vendendo drogas (fls. 06). Pois bem. Agora, o policial Marcelo disse que patrulhava pelo local, quando avistou um indivíduo deixando algo na calçada. Ao visualizar a viatura, o acusado tentou se evadir, de bicicleta, mas caiu. O réu foi abordado e algumas porções foram encontradas com ele. O local onde o réu manipulava (tapete de grama), dentro de uma carteira, foram encontradas mais porções. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, a confissão, a apreensão de quantia em dinheiro e as demais circunstâncias do caso concreto atestam que as substâncias se destinavam ao tráfico. Registre-se que nada está a indicar que a testemunha esteja a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Repise-se que houve confissão, o que corrobora a versão incriminatória. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta Maus antecedentes é primário (fls. 30/33). Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O regime prisional poderá ser o inicialmente aberto e nada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: A Defensoria Pública representa o acusado, que foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado, pelas razões a seguir. I. DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. Da absolvição por insuficiência de provas. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. O policial Marcelo Ribeiro da Cruz, ouvido em juízo, declarou que faziam patrulhamento no bairro, quando avistaram um indivíduo mexendo no solo, o que gerou suspeita. Ele estava com uma bicicleta. Quando ele viu a viatura,

tentou empreender fuga. Ao revistá-lo, encontraram 10 pinos de cocaína. No local que ele mexia, localizaram mais entorpecentes. Indagado, confessou que vendia os entorpecentes. No entanto, Excelência, não é possível embasar eventual condenação tão somente pela apreensão de droga e suposta confissão informal. Em primeiro lugar, o réu não foi visto mantendo contato com qualquer pessoa e, além disso, nenhum apetrecho para o tráfico foi apreendido em seu poder. Em segundo lugar, além de a confissão não ser motivo idôneo para condenação, é certo que o acusado estava desamparado de advogado particular. A acusação não se desincumbiu o ônus de comprovar os fatos que alega. Tais situações colocam em dúvida a versão apresentada. Diante disso, é o caso de absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 - grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Em caso de condenação, na primeira fase da dosimetria das reprimendas, cabe ressaltar que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, eis que a culpabilidade da ação do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal, não tendo havido, ainda, maiores consequências da prática delitiva. Outrossim, na segunda fase, pleiteia seja considerada a atenuante da confissão espontânea, caso valorada pela sentença. Finalmente, quanto ao regime inicial, requer que seja fixado regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Pugna-se,

por fim, com fundamento no art. 8º, item 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. FERNANDE JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 18 h, na Rua Pilar do Sul, n. 595, Vila Paulo Ayres, nesta Cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, setenta e cinco porções de “cocaína”, com peso de 67,78 gramas; trinta e seis porções de “maconha”, com peso de 85,58 gramas; e sete porções de “crack”, com peso de 4,81 gramas. O Réu foi notificado por edital, fls. 110 e apresentou defesa preliminar, fls. 119/120. A denúncia foi recebida, fls. 121, e o Réu, citado por edital, fls. 126/127. O Promotor de Justiça requereu a

decretação da prisão preventiva, bem como a suspensão do feito, fls. 132. Após o decurso do prazo do edital, o Réu não compareceu em Juízo e não constituiu Defensor, deste modo o feito foi suspenso com fundamento no art. 366, CPP, e na oportunidade foi decretada a prisão preventiva, fls. 133/134. O mandado de prisão foi cumprido, fls. 145/148, na sequência o Acusado foi citado pessoalmente, fls. 155. A Defensoria Pública requereu a liberdade provisória, fls. 159/164, o Representante Ministerial manifestou-se, fls. 168, e o pedido foi acolhido, fls. 169/170. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha presente. Foi decretada a revelia do Réu. Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição e, de forma subsidiária, benefícios. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 09/11, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 15/16, no Laudo de Constatação, fls. 19, bem como no Exame químico-toxicológico n. 44.504/2021, fls. 58/61, constatando-se a presença dos princípios ativos TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e Cocaína. Marcelo Ribeiro da Cruz, policial militar, testemunha, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o Réu abaixado, ele mexia em algo; ao ver a viatura, o Acusado saiu com a bicicleta e foi em direção aos policiais, e, ao perceber que seria abordado, tentou andar mais rápido e caiu; com o Réu houve apreensão de dez saquinhos com "cocaína"; foram ao local onde ele mexia, havia placas de grama, e, embaixo, encontraram o restante dos entorpecentes. O Acusado admitiu o tráfico de entorpecentes. Disse que receberia R\$ 100,00 pela venda das drogas. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, as policiais estavam em serviço quando viram o Réu, o qual mexia em um local e, ao vê-los, saiu com a bicicleta e foi em direção aos policiais, porém, ao perceber que seria abordado, tentou acelerar o deslocamento e caiu; abordado, com ele houve apreensão de dez porções de "cocaína"; os policiais encontraram, no local onde mexia o Réu, as outras porções de "cocaína". Destarte, as drogas, pela quantidade, pela forma de separação e pelo número de porções, claramente, eram destinadas ao comércio ilícito. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecentes, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, guardar e manter em depósito, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu é menor de 21 anos, logo faz jus à atenuante, com redução de 1/6. Todavia, na segunda etapa, a atenuante não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo

legal". Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração.

- Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar FERNANDE JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 01 de setembro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA